

1514697-78.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/11/2022

... para confirmação da condenação pela associação para o tráfico.

Como é cediço, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o crime de associação ao tráfico exige ânimo associativo permanente, elemento este não demonstrado nos autos.

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, e a conduta dos réus subsumem-se, in totum, ao crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1514697-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514697-78.2022.8.26.0228 - 2022/000801

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AUGUSTO DE FRANCA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

JOSE AUGUSTO DE FRANCA, JORGE EDUARDO MOREIRA MALTA e NEWTON COSTA SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 (curso material), do Código Penal, porque, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 15h47min, na residência situada na Rua Joaquim Guimarães, nº 385, apto 19, bloco 10, Raposo Tavares, nesta cidade e Comarca, associados para o tráfico de drogas, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 124 (cento e vinte quatro) "tabletes" contendo substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha" e 53 (cinquenta e três) invólucros plásticos também contendo substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha" (peso líquido total: 3.059,8 gramas); e 04 (quatro) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada "cocaína" (peso líquido: 1,1 gramas),

substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica.

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2022 e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 157/159).

Os réus constituíram patrono nos autos e apresentaram defesas prévias (fls. 162/165 e 216/219).

Foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 205/208 e 233/234).

Informação acerca do falecimento do réu Newton às fls. 312/315.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas policiais e, ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos IV, V ou VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação para uso de entorpecente, a fixação de pena mínima, o reconhecimento da confissão e desconsideração da reincidência, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a imposição de regime aberto, e o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A prova da materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência nº CT3302-2/2022 (fls. 02/07), laudo de constatação preliminar (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 50/51), laudos periciais (fls. 188/193), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 340/342), e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, Policiais Militares foram acionados no local dos fatos para apurar, inicialmente, ocorrência versando sobre sequestro.

No local, um conjunto habitacional, visualizaram um indivíduo no interior de um veículo cinza, de características similares à notícia, e portando uma bolsa com odor de “maconha”, mas nada ilícito foi localizado. Contudo, ante a suspeita dos fatos, deliberaram por adentrar no prédio e, diante do forte odor de “maconha”, os Policiais suspeitaram que se tratava, na verdade, de denúncia sobre “casa bomba”.

Assim, os Policiais bateram na porta do apartamento que exalava odor mais forte, qual seja, apto 19, bloco 10, e foram atendidos pelo denunciado NEWTON, vulgo “KARATÊ”, que franqueou a entrada.

De imediato, os Policiais já visualizaram porções de “maconha” e artefatos para a sua produção sobre a mesa; bem como se depararam com o denunciado JORGE escondendo tablets de “maconha” em um cesto de roupas, estando o denunciado JOSE AUGUSTO no mesmo local.

Diante dos fatos, foi solicitado apoio e, após vistoria no imóvel, foram apreendidos: uma máquina seladora automática (para embalar drogas), uma balança de precisão, R\$25,00 em espécie e os entorpecentes já descritos. Ainda, os Policiais constataram uma janela aberta, com porções de “maconha” em cima do parapeito, que

dava acesso ao pátio do prédio, onde também foram localizados resquícios de "maconha", a evidenciar terem sido dispensados entorpecentes por meio deste local.

Na delegacia, NEWTON COSTA SANTOS e os réus JOSE AUGUSTO DE FRANCA e JORGE EDUARDO MOREIRA MALTA optaram por permanecerem em silêncio (fls. 16/18).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os réus negaram os fatos que lhe são atribuídos.

O réu JOSÉ disse que no dia dos fatos estava trabalhando na empresa da sua mãe com a entrega de marmitas, quando se encontrou com NEWTON, ocasião em que pediu maconha, pois é usuário. Disse que NEWTON já havia encontrado com o corréu JORGE EDUARDO que lhe prestaria um serviço. Posteriormente foi até o apartamento de NEWTON para comprar maconha, momento em que o corréu JORGE EDUARDO chegou. Ele não tinha conhecimento do serviço que ia prestar ao saber o que se tratava, começou a discutir com NEWTON, quando a polícia chegou. Neste momento, sua reação foi se esconder em um dos quartos, deitar-se na cama e disfarçar que estava dormindo. Disse que NEWTON é conhecido como traficante e sempre comprava droga dele. Não conhecia os policiais anteriormente. Mora no bloco 13 há 29 anos, sendo que os fatos se deram no bloco 10. Afirmar ser usuário de maconha há dez anos. A adolescente era sobrinha do NEWTON.

O réu JORGE afirmou que o corréu NEWTON havia chamado para fazer um serviço. Assim, por volta das 12hs encontrou com NEWTON na rua e combinaram de se encontrarem mais tarde. Ao entrar no apartamento de NEWTON se deparou com um monte de droga, ocasião em que ele pediu que o ajudasse e que lhe pagaria. De pronto falou que não prestaria este tipo de serviço, mas ele insistiu. Em seguida, chegou o corréu JOSÉ AUGUSTO para comprar maconha. Ocorre que, depois de uns 10 a 15 minutos ouviram um barulho e verificaram que era a polícia. Assim, com receio, correu para um cômodo em que estava uma adolescente, vindo a enviar uma mensagem para sua esposa afirmando que ia ser preso. Disse que NEWTON abriu a porta e os policiais lhe deram voz de prisão. Nega que estivesse segurando uma sacola em suas mãos. Não conhecia os policiais anteriormente. Mora no local desde que nasceu, sendo que não tinha conhecimento do envolvimento de NEWTON com o tráfico de drogas. Já chegou a prestar serviços de pintura para NEWTON. Por ocasião da abordagem, o corréu JOSÉ AUGUSTO correu para o outro quarto. Não soube informar se a adolescente era sobrinha do corréu NEWTON.

A fala dos réus, contudo, encontra-se isolada com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvida de que os acusados praticaram o delito que lhes é imputado.

Vejamos a prova do contraditório:

A testemunha Rodrigo Antunes Seleznevas, policial militar e presente na diligência que prendeu os réus em flagrante, relatou que irradiou via Copom um suposto sequestro em andamento na comunidade na Vila Guimarães, onde há prédios de Cohab. Chegando ao local, avistaram um veículo prata, sobre o qual já havia denúncias de que era usado para o transporte de drogas. Na condução estava um indivíduo e feita busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém o veículo estava com forte cheiro de maconha. Junto com outro policial, adentrou no prédio em frente, para o qual o indivíduo ficava olhando, e, então, sentiram um forte cheiro de maconha vindo de um apartamento do último andar. Foram atendidos por Newton que franqueou a entrada e logo puderam ver uma mesa com maconha, a qual tentaram esconder com uma toalha. Havia também tábua de cortar, faca e balança de precisão. Newton disse que indivíduos haviam levado a droga até o local e o obrigado a guardá-las. O réu Jorge Eduardo foi surpreendido escondendo drogas dentro de um cesto de roupas sujas e o outro rapaz estava deitado em uma cama com uma adolescente de 12 anos fingindo que

estava dormindo. Na ocasião, Newton disse que a menina de 12 anos e uma outra criança de 8 anos eram sobrinhos. Sobre a droga, os indivíduos afirmaram que eram de Newton. Foi localizado máquina de embalar droga. Havia drogas pelo apartamento todo. Era uma casa bomba. Conhecia apenas Newton, pois já havia sido flagrado droga no apartamento ao lado, quando então foi dito que a droga era de Newton, porém nada foi provado em relação a ele. O veículo era de propriedade do irmão do suposto dono da comunidade, dono do tráfico. O indivíduo que estava no veículo era irmão do proprietário do veículo e foi relacionado no boletim de ocorrência. Não conhecia os outros indivíduos, apenas Newton. Pelo que se recorda o edifício tinha sete andares. Os apetrechos estavam na mesa da sala, no chão da sala (tábua e faca) e no corredor (máquina de embalagem). As drogas estavam em tabletes em diversas formas e tamanhos. Os policiais estavam com câmera. Costuma fazer abordagens na região. Recebeu denúncia do Newton um ano antes, onde duas pessoas foram presas no apartamento ao lado. Não tem conhecimento se eram vendidas drogas no apartamento, mas sabe que em uma pracinha em frente as drogas são comercializadas. Newton afirmou que os indivíduos que entraram no apartamento e lá deixaram as drogas eram perigosos e por isso cedeu. Não se recorda se ele citou nomes. Não conhecia o réu Jorge Eduardo. Não tem conhecimento há quanto tempo o réu Jorge Eduardo estava no local. Jorge Eduardo e o outro indivíduo estavam com roupas comuns. Não tinha como saber quem colocou as drogas no parapeito da janela.

Relato semelhante foi proferido pela testemunha William de Souza Melo, também policial militar e presente na diligência. Disse que estava em serviço, quando recebeu chamado via COPOM acerca de suposta ocorrência de sequestro, e lá chegando se depararam com um veículo cinza, que segundo seu parceiro costumava transportar drogas. Realizada abordagem do condutor, nada de ilícito foi encontrado, embora sentisse um forte odor de maconha. Neste momento tal indivíduo olhou para cima em direção aos prédio, razão pela qual resolveram diligenciar pelo local. A medida em que subiam, o odor de maconha aumentava, quando então no ultimo andar resolveram bater no apartamento local dos fatos, momento em que foram atendido por NEWTON, o qual já é conhecido dos meios policiais como sendo conivente, mas não traficante. Neste instante pode ver a existência de diversas drogas espalhadas pelo local. Ao ser indagado, NEWTON afirmou que estava sendo coagido a guardar as drogas e que os demais réus estavam se escondendo. Havia droga espalhada pela mesa e algumas já embaladas em uma sacola preta. Não se recorda quais drogas foram apreendidas, mas a maior parte era maconha. Também foram encontradas máquinas para embalagem de cocaína, balança de precisão e uma tabua para corte de maconha. Ademais, logo que a equipe entrou, se deparou com um indivíduo identificado por Jorge ocultando droga em um saco plástico e outro chamado José, em outro quarto, deitado na cama, fingindo estar dormindo. Havia entorpecentes em vários cômodos, móveis e até na janela, aparentemente sendo jogada para fora. Com a chegada do apoio, todos foram conduzidos para o distrito policial, pois cada uma apresentava uma versão. Não conhecia nenhum dos réus, sendo que os demais afirmaram que ao ver a viatura se esconderam no apartamento de NEWTON, pois ficaram com medo. Afirma que subiram uns 3 a 4 andares, que era o último. Era NEWTON que morava no local. Também havia um garoto e uma adolescente no local. Não soube informar quem arremessou as drogas pela janela. Apenas NEWTON morava no local, sendo que ele era conhecido por "karate". JOÃO AUGUSTO falou que estava morando temporariamente no local. Já JORGE EDUARDO disse que tinha corrido para se esconder, e quando adentraram ao local, pode ver ele tentando esconder uma sacola preta com as drogas nas mãos, sendo que no cômodo oposto estava o JOÃO AUGUSTO.

Como é cediço, os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos. Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos, mostra-se suficiente para a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de entorpecentes, visto que restou incontroverso que os réus, agindo em conjunto e com unidade de propósitos entre si e com Newton, guardavam e tinham em depósito, para entrega e consumo alheio, substâncias entorpecentes denominadas popularmente como maconha e cocaína.

Os depoimentos dos policiais demonstraram de modo firme e convincente o flagrante ocorrido, descrevendo toda a operação realizada até a apreensão das drogas. Segundo seus relatos, acionados acerca de um suposto sequestro, dirigiram-se ao local indicado, onde se depararam com um forte odor de maconha. Foram, então, atendidos por Newton, que franqueou a entrada no imóvel, e, em seu interior, onde também estavam os réus José e Jorge, foram encontrados, além das drogas apreendidas, apetrechos relacionados a mercancia, bem como dinheiro em espécie.

Com efeito, as circunstâncias que antecederam e concorreram à prisão em flagrante dos acusados, a natureza, variedade e quantidade das substâncias apreendidas (124 "tabletes" e 53 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha" (peso líquido total: 3.059,8 gramas); e 04 (quatro) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada "cocaína" (peso líquido: 1,1 gramas)), bem como a forma como estavam acondicionadas, em porções individuais, prontas para a comercialização, e, ainda, em tabletes, para repartição posterior, acompanhadas de dinheiro e apetrechos relacionados à comercialização, indicam que os réus, juntamente com Newton, as guardavam e tinham em depósito com o único fim de entregá-las ao consumo de terceiros.

Inegável, portanto, a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito, diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento, circunstâncias e local da apreensão.

Ao contrário do alegado pela defesa, não se admitem insurgências generalizadas contra depoimentos de servidores policiais. Presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação aos réus, que os motivassem a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente.

Ressalta-se, ainda, que a abordagem policial decorre do exercício do Estado do poder de polícia, que tem o dever de prevenir delitos e condutas que representem ofensa à ordem pública. No caso, os policiais militares foram acionados acerca de um suposto sequestro e, ao chegaram no local, sentiram forte odor de maconha, sendo, então, encontradas as drogas em poder dos réus.

O fato é que guardar e ter em depósito é fato típico penal e os acusados foram surpreendidos na posse das drogas. A ação policial, portanto, resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante dos réus. Assim sendo, diante desse cenário não há que se falar em ausência de justificativa para a abordagem dos acusados.

Também, não há que se falar em violação de domicílio. Com efeito, o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades "ter em depósito" e "guardar" são crimes permanentes. Em assim sendo, há justa causa para busca e apreensão, independentemente de prévia ordem judicial para tanto, sem que isto venha a

caracterizar violação ao domicílio. E isto ocorre porque tais modalidades de crimes se encontram caracterizados enquanto a droga estiver em poder do infrator, incidindo a excepcionalidade do art. 5º, XI, da CF, consoante entendimento pacífico do c. STJ:

O estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. "É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). (HC n. 730.622/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Ainda, sobre a justa causa:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

A versão apresentada pelos réus de que as drogas pertenciam ao falecido NEWTON, não lhes socorrem, notadamente diante das contradições apresentadas em seus interrogatórios.

Enquanto o corréu JOSÉ AUGUSTO afirmou que já se encontrava no apartamento de NEWTON quando JORGE EDUARDO chegou, este, de forma diversa, relatou que JOSÉ AUGUSTO chegou depois de ter iniciado uma discussão com NEWTON acerca do serviço solicitado.

Já JOSÉ AUGUSTO relatou que NEWTON era conhecido como traficante, circunstância esta que JORGE EDUARDO relatou desconhecer, embora já tenha prestado serviços ao falecido e residisse no local desde a infância.

Ou seja, a versão exculpatória apresentada pelos corréus, ao atribuir com exclusividade a propriedade das drogas ao falecido corréu NEWTON, mostra-se falsa quando confrontada aos depoimentos policiais, que narram, de forma uníssona, que os acusados foram encontrados em poder dos entorpecentes, os quais, certamente, eram destinados à comercialização, bem como diante das contrições apontadas em seus interrogatórios.

Com efeito, o ônus de provar situação diversa da citada é do réu, como ensina Damásio de Jesus:

Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o

réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria. No tocante ao fato concreto cometido pelo sujeito, incumbe à acusação a prova dos elementos do tipo, sejam objetivos, normativos ou subjetivos. Em relação aos delitos materiais, a prova acusatória deve estender-se à demonstração da realização da conduta, da produção do resultado e do nexo de causalidade entre uma e outro. A prova do dolo e da culpa, elementos do tipo, incumbe também à acusação (contra, no sentido de que em decorrência da demonstração do dolo e da autoria o dolo é presumido: TJRJ, ACrim 1.316, RT 649/302). Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.

No entanto, em que pese o esforço da combativa Defesa, tem-se que nenhuma prova quanto ao alegado pelos réus foi produzida nos autos.

Patente, portanto, a traficância.

Todavia, o delito descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 não se caracterizou.

Com efeito. A prova coligida é insuficiente para a configuração do delito de associação para o tráfico, pois, a despeito de terem sido flagrados na posse de grande quantidade de entorpecentes, bem como diversos apetrechos, em local conhecido como "casa bomba", por si só, desprovidos de outros elementos probatórios que indicasse a existência de situações anteriores, delimitadas no tempo e no espaço, caracterizadoras da sociedade criminosa e sua permanência e constância, não é suficiente para confirmação da condenação pela associação para o tráfico.

Como é cediço, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o crime de associação ao tráfico exige ânimo associativo permanente, elemento este não demonstrado nos autos.

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, e a conduta dos réus subsomem-se, in totum, ao crime tipificado no art. 33, caput, do Código Penal.

Passo a dosar a pena dos réus.

a) Com relação ao réu JOSE AUGUSTO DE FRANCA:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, e art. 42, da Lei 11.343/06, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Observo, no mais, que o réu é reincidente, o que será considerado na segunda etapa da dosimetria da pena (fls. 73/74).

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), havida do seguinte feito: 1) F. 1528271-76.2019.8.26.0228, da r. 26ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 29/01/2020, pelo delito de tráfico de entorpecentes (fls. 73/74). Assim sendo, por se tratar de reincidência específica, exaspero a pena em um quinto, resultando em seis anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos dias-multa.

Não havendo causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena fixada.

Não é o caso de aplicação da causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista ser o réu reincidente específico, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.

Convém mencionar que o fato de se considerar os maus antecedentes e a reincidência, nesta etapa da dosimetria da pena, para se afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, não implica em "bis in idem". Elas possuem finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, gerando efeitos diversos.

Ser primário e com bons antecedentes é condição 'sine qua non' para que o traficante eventual possa merecer a causa especial de diminuição de pena. E o acréscimo pelo fato de o agente ter sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, consubstancia agravante a ser aplicável em todo e qualquer processo criminal.

A matéria não é nova e já foi enfrentada com vagar pelo c. STJ:

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - Por decorrer de expressa previsão legal descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inexistente bis in idem na utilização da reincidência como agravante e para justificar o afastamento do tráfico privilegiado, pois é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas da dosimetria da pena, gerando efeitos diversos. Precedentes. - Hipótese em que o tráfico privilegiado não foi reconhecido com base na reincidência do acusado, fundamentação idônea e que não enseja constrangimento ilegal. [...] - Habeas corpus não conhecido.

Ainda:

Apenas ressalto que, consoante reiterada jurisprudência, a valoração dos maus antecedentes na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado.

Não há, portanto, bis in idem.

Por tudo isto, diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível a sua incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena.

Assim, levando em consideração tais elementos, nego o benefício de redução da pena. Torno, portanto, definitiva a pena fixada alhures.

b) Quanto ao réu JORGE EDUARDO MOREIRA MALTA:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, e art. 42, da Lei 11.343/06, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Também, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 70).

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena já fixada.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, pois o réu é primário e de bons antecedentes e, pelo que se colheu em juízo, não é integrante de organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena-base em 2/3, ou seja, em um ano e oito meses de reclusão, bem como a solter cento e sessenta e seis dias-multa, que passa a ser definitiva por ausência de outras circunstâncias.

Conforme vem sendo decidido de forma reiterada pelo c. STJ, o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade deve ser o aberto, em se tratando de crime de tráfico privilegiado (afastada a hediondez), conforme entendimento do e. STF, máxime sendo as circunstâncias judiciais favoráveis (HC 118.533/MS, Min^a Cármen Lúcia, j. 23.06.16).

Com efeito, considerando que o acusado é primário, não possui maus antecedentes, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e as circunstâncias do caso fazem crer que se trata de traficante pequeno, sem vínculo com organização criminosa, com reconhecimento do tráfico privilegiado, cabível a fixação do regime aberto.

Pelas mesmas razões, faz jus ao benefício previsto no art. 44 do CP, entendendo como suficiente à reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: 1) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, em entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções; e 2) prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, nos termos do Provimento nº 01/2013 da CGJ.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa, para o delito, no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar:

a) JOSE AUGUSTO DE FRANCA, RG: 49104111, nascido em 08/08/1992, natural de São Paulo - SP, filho de JOSE ROBERTO DE FRANCA e MARIA JOSE DO O, às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no padrão unitário, por violação ao art. 33, caput, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06;

b) JORGE EDUARDO MOREIRA MALTA, RG: 49244308, nascido em 01/10/1993, natural de São Paulo - SP, filho de JORGE DE ASSIS MALTA e MARIA HELENA MOREIRA CLEMENTE, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituído nos termos acima, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa), no padrão unitário, por violação ao art. 33, caput, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizam o decreto de prisão preventiva do réu JOSÉ AUGUSTO, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos

subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao acusado pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo os réu JOSÉ AUGUSTO na prisão em que se encontra recolhido. Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas se acaso tal providência ainda não tiver sido realizada, nos termos do art. 32 e parágrafos da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Declaro a perda dos demais objetos apreendidos (aparelho celular, balança de precisão e máquina seladora - fls. 50/51), porquanto relacionados à traficância. Autorizo a destruição.

Condeno os réus ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 05 de novembro de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA